

1502182-28.2020.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/02/2022
... sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502182-28.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502182-28.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABRICIO CRUZ DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

FABRICIO CRUZ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com Caio Cesar do Nascimento Costa, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas da denúncia, em ocasião de calamidade pública, agindo previamente acordados e com unidade de desígnios com Caio Cesar, mediante escalada, tentaram subtrair, para si próprios, um ventilador de teto pertencente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Fernando dos Reis não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Recebida a denúncia, o acusado Fabricio foi citado e ofereceu resposta à acusação.

O codenunciado Caio não foi localizado para ser citado pessoalmente e, citado por edital, sem que tenha constituído defensor, foram os autos suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, o acusado Fabricio foi interrogado.

Realizados os debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu Fabricio nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos relativos ao apenamento.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por atipicidade de conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Deixou de requerer a absolvição do réu por falta de provas, diante de sua confissão. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o afastamento da circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública, bem como o afastamento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno, e o reconhecimento da tentativa com a redução da pena em seu patamar máximo, formulando pedidos, ainda, quanto à fixação do regime prisional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que passava por situação difícil, havia usado drogas, estava vivendo nas ruas e acabou por deixar-se levar por seu amigo Caio Cesar, concordando com a prática do crime. Declarou que ingressou no local dos fatos mediante escalada.

Corroborando a confissão do réu, a testemunha policial militar Wesley Luiz de Araújo Rossi, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento com sua parceira de farda quando avistou dois indivíduos em uma escola, sendo que um deles estava ao lado de dentro do local e passava um ventilador por cima do muro ao outro, que estava ao lado de fora. Disse que, realizada a abordagem de ambos, constatou-se que havia um local, dentro da escola, por onde os meliantes poderiam ter ingressado para furtar o bem, bem como verificou-se que estava faltando um ventilador no refeitório, além de ter sido constatado que, no ventilador apreendido com os meliantes havia um número de patrimônio. Não recordou se o acusado e seu comparsa forneceram esclarecimentos sobre os fatos quando abordados. Narrou que o muro da escola era baixo, medindo cerca de dois metros de altura, porém o local pelo qual o acusado e seu comparsa teriam ingressado para a subtração do ventilador tratava-se de uma entrada no forro, aos fundos da escola, local alto e que demandaria que um subisse no ombro do outro para acessá-lo. Relatou que nenhum representante da escola esteve no local dos fatos, onde também não havia um caseiro. Esclareceu que viu o momento em que o acusado e seu comparsa estavam passando o ventilador por cima do muro e afirmou que o réu era o indivíduo que estava ao lado externo, recebendo o objeto pelo muro. Asseverou que ambos foram abordados já ao lado de fora da escola, na rua. Declarou que os fatos ocorreram durante a madrugada. Não conhecia o réu e seu comparsa

anteriormente aos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Bianca Bento Ferreira, ouvida em Juízo, narrou que, durante patrulhamento, viu dois indivíduos, um deles dentro da escola, passando um ventilador pelo muro da escola ao outro, que estava ao lado externo. Disse que, no momento em que o meliante que estava dentro da escola pulou o muro para o lado de fora, foi realizada a abordagem. Declarou que o muro possuía cerca de 3,5 metros de altura e que, após a abordagem e conversa com os dois indivíduos, foi feita averiguação no local, sendo identificada a entrada por uma espécie de sótão, que ambos teriam utilizado para o ingresso e furto do ventilador. Consignou que essa entrada estava em local bastante alto e houve dificuldade da equipe policial para acessar o local. Afirmou que o ventilador estava identificado como patrimônio da escola. Declarou que o réu e seu comparsa admitiram, informalmente, ter ingressado na escola para furtar o ventilador. Esclareceu que a abordagem foi realizada quando o meliante que estava dentro da escola pulou para o lado externo e ambos estavam ainda bem próximos ao muro do local. Não conhecia o réu e seu comparsa anteriormente aos fatos.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante dos relatos das testemunhas policiais militares, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, e que corroboraram a confissão do acusado Fabricio em Juízo, não há dúvidas em se concluir que este efetivamente participou do delito descrito na denúncia.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante.

Note-se que os depoimentos das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos com suas declarações prestadas na fase extrajudicial, tendo as testemunhas apresentado relatos detalhados acerca da abordagem do réu e de seu comparsa, bem como da dinâmica da ação criminosa que puderam presenciar e também foi por eles constatada.

Quanto aos testemunhos dos agentes policiais, com enorme grau de confiabilidade, prestam-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Note-se que as testemunhas asseveraram ter surpreendido o acusado e seu comparsa

rentes ao muro da escola, tendo a testemunha Wesley consignado que o réu estava já ao lado externo do muro, recebendo o ventilador que era passado por seu cúmplice por cima do muro.

Afirmaram, ainda, que o muro da escola possuía, ao menos, dois metros e que a entrada para o interior da edificação localizava-se em uma espécie de forro ou sótão.

Consignaram que o local era bastante alto, acrescentando a testemunha Bianca que a própria equipe policial encontrou dificuldades para o ingresso por aquele local.

Dessa forma, o crime de furto e a participação do acusado Fabricio restaram bem demonstrados nos autos.

O crime realmente não se consumou, uma vez que o acusado e seu comparsa não conseguiram apoderar-se da res, invertendo sua posse. Depreende-se da prova produzida que o réu e seu cúmplice foram surpreendidos quando passavam o ventilador por cima do muro e ambos foram abordados e detidos já ao lado externo do muro da escola.

A qualificadora do concurso de agentes restou bem demonstrada nos autos. As testemunhas policiais bem descreveram que o acusado estava com outro indivíduo, que também foi abordado e preso em flagrante, ambos dividindo as tarefas no momento do crime, de maneira a executá-lo de forma mais eficiente.

Da mesma forma, a qualificadora da escalada, além de ter sido confessada pelo acusado, foi suficientemente comprovada pelo laudo pericial de fls. 156/159. Note-se que o exame realizado demonstrou que o imóvel era cercado por muro e portões externos que mediam, aproximadamente, 2,10 metros, sendo destacado, ainda, pelas testemunhas policiais que não somente o muro externo foi ultrapassado pelos meliantes, mas também foi necessário o acesso à área interna da edificação por entrada em local ainda mais alto.

Outrossim, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal deve ser aplicada, uma vez que restou evidenciado que o crime foi cometido durante a madrugada.

Ainda, a causa de aumento deve ser reconhecida, ainda que praticada contra escola ou estabelecimento comercial.

Observe-se que a testemunha policial Wesley consignou que, no local dos fatos, não havia caseiro, nem qualquer outro responsável.

Não há dúvidas de que o acusado realizou a subtração de bem pertencente à escola justamente em horário de menor vigilância sobre os bens, que, conseqüentemente, ocasiona a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, " a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Dje 29/10/2020).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação

da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime".

3. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato da res estar mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30min durante o inverno, ou seja, ainda durante na madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico.

4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "[...] a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018).

5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 674.534/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) (grifo nosso)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CRIME OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL ? CP.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.

2 . Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (grifo nosso)

Finalmente, em que pese ao entendimento da Defesa, não cabe a aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta apenas aferir o pequeno valor da res. Sua aplicação deve ser feita com certas restrições, principalmente, no que se relaciona à delimitação do que a sociedade tolera de fato ou do que seja um crime insignificante. Não se pode abrir espaço para delitos comprometedores da ordem social, mesmo sendo pequenos.

Há que se considerar vários critérios, dentre eles, o desvalor da ação.

O réu, em concurso de agentes e durante repouso noturno, decidiu ingressar em uma escola pública, para de lá subtrair um ventilador de teto.

Tal conduta é totalmente reprovável, não se podendo aceitar que sejam toleradas pela sociedade, ainda que o bem furtado possa ser considerado de pouca significância.

Além disso, o acusado possui maus antecedentes e é reincidente.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC-106292 /MG, DJe-024, 07.02.2017).

Nesse mesmo sentido:

"(...) 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas

irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada.” (HC 102088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 20/05/2010)

Dessa forma, não é caso de aplicação do princípio da insignificância.

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é detentor de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 28 e 30 e informações de fls. 46/47 da folha de antecedentes, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado é reincidente pela prática de mesma espécie de crime contra o patrimônio, conforme certidão criminal de fls. 29 e informação de fls. 47 da folha de antecedentes, razão pela qual deve a pena ser acrescida em 1/3, ficando fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que a infração penal foi cometida em ocasião de calamidade pública, agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática da infração penal. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Contudo, reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea, ficam estas circunstâncias compensadas.

Na última fase do cálculo da pena, verifico que está presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 155, do Código Penal. Assim, aplicado o aumento de 1/3, resulta a pena final de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Reconhecida, por fim, a tentativa e considerando o iter criminis percorrido, considerando que o acusado e seu comparsa já estavam retirando do perímetro da escola o ventilador e foram abordados já ao lado externo do muro do local, a pena é reduzida de 1/3, resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Fixo ao acusado o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante de sua reincidência e das circunstâncias judiciais negativas.

Pelos motivos acima expostos, não estão presentes os requisitos legais do artigo 44

do Código Penal, de modo que deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sendo, pela mesma razão, também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito dos seus comportamentos no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABRICIO CRUZ DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva. O acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são negativas. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de

reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 08 de fevereiro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA